

1501524-10.2019.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... da denúncia acerca da ocorrência de tráfico no local, sendo confirmado pelos Policiais que o denunciado possuía as características indicadas e que no seu veículo, também apontado na denúncia, havia diversas porções de cocaína, individualmente prontas para venda, evidente a prática do crime de tráfico de drogas"

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501524-10.2019.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501524-10.2019.8.26.0319

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RAFAEL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

WESLEY RAFAEL DA SILVA, qualificado às fls. 07, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois alega-se que, "no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 04h40min, na Avenida Prefeito Jácomo Nicolau Pacola, Núcleo Habitacional João Zillo, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, tinha em depósito, para venda, 15 eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 10,0g, substância entorpecente prevista na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, Policiais Militares deslocaram-se ao local dos fatos, tendo em vista denúncia acerca do comércio de entorpecentes realizado por um indivíduo branco, com cabelos loiros. A denúncia também apontava que o indivíduo estaria com um veículo Fiat/Palio, cor prateada, ao lado da empresa "Thomriss". No local, os Policiais se depararam com o denunciado, o qual tinha as mesmas características apontadas na denúncia, e outros indivíduos. Foi realizada a abordagem e com eles nada de ilícito

foi encontrado. No veículo indicado na denúncia, de propriedade do denunciado, foi encontrado, no porta-luvas, um invólucro plástico, contendo 15 eppendorfs de cocaína. Auto de exibição e apreensão a fls. 05. Laudo pericial a fls. 08/11. Portanto, diante da denúncia acerca da ocorrência de tráfico no local, sendo confirmado pelos Policiais que o denunciado possuía as características indicadas e que no seu veículo, também apontado na denúncia, havia diversas porções de cocaína, individualmente prontas para venda, evidente a prática do crime de tráfico de drogas”

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº 2974/2019 (fls. 03/04), o auto de exibição/apreensão (fl. 05), os termos de declarações na fase policial (fls. 07, 12, 13), o laudo pericial de entorpecentes nº 342.156/2019 (fls. 08/11) e o relatório final do inquérito policial (fls. 15/16). A denúncia foi oferecida (fl. 20). Foram juntadas aos autos cópia do Boletim de Ocorrência nº 292 e 293/2019 (fls. 23/29) e as certidões e F.A. do denunciado (fls. 35, 38). O acusado foi notificado (fl. 41). O defensor do réu apresentou defesa prévia (fls. 42/43). A denúncia foi recebida (fl. 50). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 20 de junho de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas PM Willys Fernando Cavalcanti da Silva, PM Edson Fernandes Júnior, Janaína Cristina Pires e Vanderleia Fatima Pires Iinto e, ao final, o réu foi interrogado (fl. 124).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia (fls. 127/136).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu; que, em caso de condenação, requereu que seja fixado a prática do crime disposto no art. 28 da Lei 11.343/06; que, subsidiariamente, seja concedida a diminuição da pena prevista a no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo considerando a pequena quantidade de drogas; que sejam concedidas medidas restritivas de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como que o regime inicial de cumprimento de pena inicial seja diverso do fechado (fls. 140/154).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, pois é imperiosa a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada a materialidade e autoria de tal infração.

A materialidade vem consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), no auto de exibição e apreensão (fls. 05), nos termos de declaração (fls. 07, 12, 13), no laudo pericial de nº 342.156/2019 (fls. 08/11), na cópia do Boletim de Ocorrência nº 292 e 293/2019 (fls. 23/29), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Segundo o laudo de exibição e apreensão foram apreendidos: 15 eppendorfs de cocaína, pesando 10,0 gramas (fl. 05).

No laudo pericial de nº 342.156/2019 restou consignado: 15 porções de substância em pó branca, embaladas em tubos plásticos do tipo “eppendorf” de cor laranja. Apresentavam peso líquido total de 2,61 g (dois gramas e sessenta e um centigramas)”. Da análise do material descrito revelou o seguinte resultado “[...] A) DETECTADA a presença da substância COCAÍNA substância relacionada na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores [...]” (fls. 08/11).

Desta forma, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, ressaltando-se que o réu, por evidente, não tinha qualquer autorização para ter os alucinógenos. Logo, a materialidade quanto ao entorpecente apreendido está devidamente configurada.

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do réu, com a observação de que o quadro probatório infra exposto não demonstra, com a absoluta certeza e segurança necessária e exigível, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, senão vejamos.

O acusado Wesley Rafael Da Silva declarou, em juízo, "que não é verdadeira a denúncia, pois não estava traficando; que a droga era do interrogado para uso próprio; que a droga era só para uso mesmo; que já estava usando drogas há oito meses; que na época o interrogado trabalhava na empresa Frigol, como auxiliar geral, com registro em carteira; que o carro Palio prata era do interrogado; que atualmente tem 23 anos, amasiado, tem um filho de 1 ano e 4 meses, trabalha como motorista de caminhão de material de construção; que tem remuneração de R\$ 2.300,00 por mês; que nunca foi preso e nem processado; que conhece a testemunhas só do dia da ocorrência e nada tem contra eles; que parou de usar drogas, sem fazer tratamento; que, quando dos fatos, não tinha dinheiro; que na época gostava de sair muito e comprou a droga em uma festa em que foi em Bauru e trouxe para usar no final de semana; que não lembra quanto pagou pela droga; que a família não sabia que o interrogado usava cocaína; que depois foi chamado para a família para conversar; que o interrogado prometeu para a família que nunca mais iria usar drogas; que o carro estava do outro lado da rua, sendo que o interrogado estava a cerca de 20 metros do carro e estava com mais pessoas; que todas essas pessoas foram revistadas e nada foi encontrado com elas; que todas as pessoas foram liberadas, menos o interrogado que, então, foi encaminhado à delegacia" (fl. 124).

Tem-se que a confissão do réu se deu apenas em relação a propriedade da substância, sendo enfático em afirmar que o entorpecente em questão era destinado apenas ao próprio uso.

Portanto, a negativa externada pelo denunciado quanto ao tráfico não é afastada pela prova oral produzido sob o crivo do contraditório.

A testemunha PM Willys Fernando Cavalcanti da Silva relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 13 anos; que na data dos fatos estava em patrulhamento com o CB Edson quando foram informados, através de denúncia anônima, de que havia um veículo Palio, próximo a empresa Thomrris, e que o condutor vendia drogas; que foram ao local e fizeram a abordagem ao veículo mencionado; que o condutor foi submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Que ao fazer busca no carro, localizaram, no interior do porta-luvas, alguns eppendorfs de cocaína prontos para comércio; que o condutor foi preso e encaminhado para a delegacia; que não se recorda se o réu trazia consigo dinheiro; que não teve contato com qualquer pessoa que tenha comprado drogas do réu; que o acusado disse, quando dos fatos, que a droga era para uso; que quando da denúncia anônima houve descrição do veículo e da pessoa, informando as vestes do condutor do veículo; que na data as características bateram com a do réu, mas não se recorda hoje dessas características; que além das roupas houve descrição das características, mas o depoente não se recorda; que só conhecia do réu de abordagens anteriores, sem ocorrência efetiva; que a denuncia anônima foi feita, salvo engano, via COPOM; que o acusado estava na companhia de mais pessoas; que não lembra se essas outras pessoas foram ou não encaminhadas à delegacia".

A testemunha PM Edson Fernandes Júnior relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 19 anos; que na data estava em patrulhamento com o PM Willys e

receberam denúncia anônima de que um elemento fazia tráfico próximo à empresa Thomrris; que ele estava com um veículo Palio cor prata; que o local já é conhecido como ponto de venda de droga; que foram ao local e, então, ao chegar visualizou o veículo Palio prata e um pessoal próximo ao carro; que feita a abordagem, fizeram vistoria em todas; que o réu se identificou como dono do carro; que com as pessoas nada foi localizado; que no carro havia 15 eppendorfs no porta-luvas, num saco plástico, prontos para venda; que todos negaram atividade ilícita; que o dono do carro foi encaminhado à delegacia; que o réu tinha dinheiro, mas o depoente não sabe a quantia; que não tiveram contato com qualquer pessoa que tivesse comprado drogas do réu; que o réu negou a propriedade da droga; que não se recorda se a denúncia foi via copom ou pessoalmente; que a denúncia falava do carro e das características do traficante, mas não especificava a pessoa "certa" do traficante; que as características era de que a pessoa era da cor branca, estatura mediana; que o local é frequentado por muitas pessoas; que não se recorda de já conhecer a pessoa do réu dos meios policiais; que foram abordadas mais pessoas com o réu, sendo que apenas o acusado foi encaminhado à delegacia, por conta da droga ter sido encontrado no carro dele; que foi apresentado o dinheiro na delegacia, mas o depoente não sabe acerca da apreensão do dinheiro pela autoridade".

A informante Janaína Cristina Pires relatou, em juízo, "que conhece o réu, pois é irmã do acusado; que não estava no local dos fatos e não viu a atuação da polícia; que em agosto de 2019 o réu tinha um Palio prata; que o réu não vendia drogas; que após os fatos a depoente passou a ter conhecimento de que o acusado era usuário de cocaína; que após os fatos a família toda conversou com o réu e, então, ele confessou que usava drogas; que o réu não passou por tratamento, mas parou de usar drogas; que o réu trabalha como motorista de caminhão da empresa Paraíso da Construção, com registro em carteira; que o réu sempre trabalhou, sendo hoje casado com filhos; que depois do ocorrido o réu nunca mais teve contato com drogas; que o réu tem um filho" .

A testemunha Vanderleia Fatima Pires Pinto relatou, em juízo, "que a depoente é tia do réu; que não presenciou a prisão do réu e nem a atuação da polícia; que não tinha conhecimento de que o réu usava drogas; que depois do ocorrido é que soube; que o réu não vendia drogas; que na época dos fatos o réu trabalhava na Frigol, fazendo serviço gerais; que o réu é trabalha na empresa Paraíso, material de construção; que após os fatos, o réu não teve mais contato com drogas; que a irmã da depoente chamou o réu para conversar com a família, oportunidade em que o réu confessou ser usuários de drogas; que hoje o réu é casado e tem um filho".

Ora, à luz da prova oral supra exposta, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante.

Consoante à denúncia, o acusado foi abordado por conta de uma denúncia anônima. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No veículo indicado na denúncia, de propriedade do denunciado, foi encontrado, no porta-luvas, um invólucro plástico, contendo 15 eppendorfs de cocaína.

É dos autos que não foi encontrado com o réu ou no veículo qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, como usualmente acontece nos casos de verdadeiros traficantes, tais como balanças de precisão, embalagens, variedade de porções, dinheiro trocado, entre outros. Aliás, é preciso ressaltar que não foi feita qualquer diligência na residência do denunciado a fim de corroborar as alegações descritas na exordial acusatória.

Obtempera-se, ainda, que não se logrou encontrar qualquer testemunha que tenha comprado drogas do réu ou, ainda, que tenha presenciado o denunciado comercializar entorpecente com um usuário.

Merece destaque o fato de que, o Policial Willys Fernando tenha relatado, sob o crivo do contraditório, "(...) que não teve contato com qualquer pessoa que tenha comprado drogas do réu; que o acusado disse, quando dos fatos, que a droga era para uso.(...). No mesmo sentido, o Policial Edson Fernandes, confirmou em juízo, "(...) que não tiveram contato com qualquer pessoa que tivesse comprado drogas do réu. (...)".

Por outro lado, a quantidade de entorpecente apreendido era pequena e, assim, plenamente compatível com a guarda do alucinógeno visando mero consumo pessoal.

Frisa-se, ainda, que a prova testemunhal é no sentido de que, na época dos fatos, o réu consumia entorpecentes e, após o episódio em questão, largou o consumo, afastando-se do mundo das drogas.

Diante desse contexto probatório, é digno de nota o fato de que o réu não era conhecido nos meios policiais e, após essa ocorrência, não se envolveu em outros crimes. Ademais, apresenta perfil pessoal diverso daquele ordinariamente ostentado pelos verdadeiros traficantes, pois trabalhava e ainda trabalha em empresas da cidade, sempre com registro em carteira, constituiu família, bem como nunca foi preso e nem processado.

Soma-se a tal que o único elemento probatório no sentido de que o acusado eventualmente poderia praticar a ilícita mercancia é a declaração dos policiais no sentido de que receberam, quando dos fatos, isolada denúncia anônima relatando que um elemento com as mesmas características e num carro Palio praticava o tráfico. Ora, tal declaração, por si só, é absolutamente insuficiente para alicerçar um decreto condenatório, sobretudo ante a ausência de outros elementos probatórios conforme supra apontado.

Assim, considerando a prova oral supra transcrita, aliada aos demais elementos probatórios presentes nos autos, reputa-se imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste Juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante, razão pela qual a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Se as provas não demonstram, com a necessária certeza, que a pequena quantidade de droga encontrada em poder dos acusados destinava-se à mercancia, deve-se promover a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o tipo do artigo 28 do mesmo diploma legal. Uma vez demonstrado que o crime de ameaça foi praticado apenas por um dos acusados, deve-se absolver o codenunciado e preservar a condenação apenas daquele primeiro. Inviável a elevação da pena-base com amparo em fundamentação genérica. Recursos parcialmente providos. De ofício, abrandaram a pena de um dos corréus relativamente ao crime do artigo 147 do CP e declararam as penas cumpridas diante do tempo de segregação provisória." (TJ-MS-APR: 00000399720198120041 MS, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 27/09/2019. 2ª Câmara Criminal).

"A distribuição do ônus da prova, compreendido nos limites da presunção de inocência, impõe ao órgão ministerial a demonstração dos fatos afirmados na denúncia. A deficiência probatória quanto a parte da droga que teria destinação ao tráfico afasta a certeza necessária para uma condenação, pois havendo dúvida, deve o acusado ser favorecido, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Sendo comprovado que apenas parte da droga destinada a uso pessoal era de propriedade do acusado, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006." (TJ-MS-APL: 00492702420168120001 MS, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª Câmara Criminal).

Ou ainda:

"Apreendida droga na posse do agente, contudo, não havendo prova suficiente da ocorrência de uma das condutas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mas tão somente do consumo próprio, desclassifica-se para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, extinguindo-se a punibilidade considerado o tempo de cumprimento de pena corporal provisória." (TJ-MS – APR: 00011437820198120024 MS, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª Câmara Criminal).

Cumpra consignar que referida lei não pune o vício, entretanto, só o fato do denunciado ter em depósito a substância, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já é suficiente para a configuração do ilícito penal descrito no art. 28 e sua respectiva condenação.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, revela-se que o denunciado não possui condenação anteriores transitada em julgado, assim, não se trata de pessoa portadora de maus antecedentes, muito menos reincidente. Ainda, é importante salientar que o denunciado ao tempo do fato era menor de 21 (vinte e um) anos.

Assim, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, bem como a primariedade do réu, fixo a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Consigna-se que a aplicação da pena de advertência revela-se suficiente para ressocializar o acusado à vida em sociedade e reintegrá-lo ao convívio social.

Oportunamente será designada a pertinente AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.

Ademais em caso de não comparecimento na audiência que será designada para a aplicação da pena de advertência, o réu incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei 11.343/06.

Fica consignado que em caso de descumprimento da pena, incorrerá o réu em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 CONDENO o réu WESLEY RAFAEL DA SILVA, RG: 56701177 6, filho de Angela Conceicao Pires e Ederval Aparecido da Silva, à pena de ADVERTÊNCIA, com a observação de que no caso de descumprimento, incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei nº 11.343/06, inclusive em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para

a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 3) Determino a devolução, ao réu, da quantia de dinheiro apreendida (fls. 05), vez que não constitui proveito aferido com a prática do crime em questão.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA